

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

暴力団A組の組員甲は、クラブで飲酒していた際、たまたま入店してきた旧知の暴力団B組の組員乙に因縁を付けられて口論になり、乙に拳で殴りかかった。乙は、これを避けた上、更に殴りかかろうとしてきた甲の胸部を拳で数回強打した。その数分後、B組の組員丙は、乙と待ち合わせをしていた上記クラブに到着し、その直後に甲の態度に激高し、いきなり甲の胸部を拳で数回強打した。甲は、全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負ったが、同傷害が乙と丙のいずれの暴行によって生じたのかは不明であった。甲は、一旦帰宅したものの怒りが収まらず、何か嫌がらせをしてやろうと考え、金属バットを持ち、覆面で顔を隠してB組事務所に行き、その玄関ドアを同バットでたたいて凹損させた。その直後、甲は、A組事務所に行き、A組の組員丁に対し、B組組員から殴られた腹いせにB組事務所の玄関ドアを凹損させたことを話した。丁は、B組との関係悪化を避けるとともに、甲の刑事責任を免れさせるため、甲との間で、犯行時間帯に甲がA組事務所に行ったことにする旨の口裏合わせをした。また、丁は、B組組員複数名による襲撃を受ける可能性もあると考え、万が一に備えて、着衣のポケットに護身用として果物ナイフを入れた。他方、乙及び丙は、上記ドアが凹損させられたとの連絡を受け、甲の仕業だろうと考え、A組事務所へ向かった。乙は、対応に出た丁に対し、「甲を出せ。」と言った。丁は、「何の話だ。」と応じたが、乙は、その態度に憤激し、「しらばっくれるな。」と言い、持っていた拳銃を取り出して丁に突き付けた。丁は、自己の身を守るため、上記ナイフで乙の腹部を1回突き刺し、乙に全治約1か月間を要する腹部刺創の傷害を負わせた。丁は、駆けつけた警察官に逮捕され、その後、逃走していた甲も上記ドアを凹損させた事実で逮捕された。丁は、甲の身柄拘束中、甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際、上記口裏合わせに従い、上記ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所に行った旨のうその供述をした。

【記述】

- ア. 乙が甲の胸部を拳で強打した行為については、甲からの侵害が、乙が甲に因縁を付けたことにより招かれたものである以上、正当防衛又は過剰防衛が成立することはない。
- イ. 乙は、甲の肋骨骨折について、丙の行為のみにより生じた可能性がある以上、丙との間で共謀が成立していない限り、傷害罪の刑事責任を負わない。
- ウ. 甲がB組事務所の玄関ドアを凹損させた行為については、同ドアが工具を使用すれば容易に取り外せる構造であった場合、建造物損壊罪は成立しない。
- エ. 丁が果物ナイフで乙の腹部を突き刺した行為については、B組組員から襲撃を受けることを予期し、凶器ともいえるナイフを準備している以上、その予期の程度にかかわらず、侵害の急迫性を欠くものといえ、正当防衛又は過剰防衛は成立しない。
- オ. 丁が、甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際、B組事務所の玄関ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所に行った旨のうその供述をした行為については、犯人隠避罪が成立する。

No441

共通R3-20

正当防衛・緊急避難

正解

ア 2

イ 2

ウ 2

エ 2

オ 1

正答率

39%

ア 誤っている

最決平 20.5.20 (百選 I 26 事件)。乙の正当防衛又は過剰防衛の成否については、乙が甲に因縁をつけた際の主観的事情によって異なる。乙が、甲を憤激させれば必ず攻撃してくるに違いないので、その機会を利用して甲を打ちのめそうと考えていた場合、乙は甲の侵害を予期し、かつ積極的加害意思を有していたとして、侵害の急迫性が否定される (最決昭 52.7.21 参照)。この場合は、乙の行為に正当防衛又は過剰防衛が成立することはない。これに対して、乙が甲による侵害を予期していたが、積極的加害意思まではなかった場合、侵害の急迫性は肯定される。そして、判例 (最決平 20.5.20) は、口論をきっかけに相手方 A に暴行をふるいその場を立ち去ったが、A から予想しない攻撃を受けて驚き、特殊警棒で A の顔面を殴打して傷害を負わせた事案において、「A の攻撃は、被告人の暴行に触発された、その直後における近接した場所での一連、一体の事態ということができ、被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから、A の攻撃が被告人の前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件事実関係の下においては、被告人の本件傷害行為は、被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」としている。同判例に照らして本記述を検討すると、たしかに、甲の攻撃は、乙が因縁をつけたことに触発された、その直後における近接した場所 (クラブ) での一連、一体の事態といえる。しかし、乙の因縁が不正の行為に当たり、自ら甲による暴行を招いたと評価できたとした場合でも、甲の攻撃の程度は乙の因縁を大きく超えていると考え、乙が甲の胸部を拳で数回強打した行為は、乙が反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為と評価される可能性がある。よって、乙の行為については、甲からの侵害が、乙が甲に因縁を付けたことにより招かれたものであっても、正当防衛又は過剰防衛が成立することはあり得る。したがって、本記述は、乙が甲の胸部を拳で強打した行為については、甲からの侵害が、乙が甲に因縁を付けたことにより招かれたものである以上、正当防衛又は過剰防衛が成立することはないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

207 条。本記述で、乙と丙が、各々共謀することなく甲の胸部を殴打したところ、肋骨骨折の傷害が生じているが、同傷害が乙丙いずれの暴行によるかは不明である。意思の連絡がない場合でも同時傷害の特例 (207 条) が適用されれば、乙と丙は傷害の共同正犯とみなされる。同時傷害の特例が適用される要件は、①暴行が当該具体的な傷害を惹起し得るものであったこと、②複数人で意思の連絡なく同一人に対し故意に暴行を加えたこと、③暴行が同一機会に行われたこと、④傷害の原因となる暴行が特定できないこと、である。本記述では、いずれも暴力団組員である乙と丙は、拳で胸部を強打しており、肋骨骨折の傷害を惹起し得る (①)、乙と丙は意思連絡なく、甲に対して故意に暴行を加えている (②)、乙が甲に暴行を加えた数分後、同じクラブにおいて、丙も暴行を加えているため同一の機会といえる (③)、肋骨骨折が乙丙いずれの暴行によって生じたか不明である (④) ことから、同時傷害の特例が適用される可能性が高い。よって、乙は、甲の肋骨骨折について、丙の行為のみにより生じた可能性があり、丙との間で共謀が成立していないとしても、傷害罪 (204 条) の刑事責任を負う余地がある。したがって、本記述は、乙は、甲の肋骨骨折について、丙の行為のみにより生じた可能性がある以上、丙との間で共謀が成立していない限り、傷害罪の刑事責任を負わないとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

最決平 19.3.20 (百選Ⅱ79 事件)。判例は、本記述と類似の事案において、建造物損壊罪 (260 条) の成立を認めている。その理由として、判例は、「建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきものであるところ、……本件ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界とのしゃ断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ、適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても、この結論は左右されない」としている。よって、甲の行為については、ドアが工具を使用すれば容易に取り外せる構造であったとしても、建造物損壊罪は成立し得る。したがって、本記述は、甲がB組事務所の玄関ドアを凹損させた行為については、同ドアが工具を使用すれば容易に取り外せる構造であった場合、建造物損壊罪は成立しないとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

最決平 29.4.26 (百選Ⅰ23 事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「刑法 36 条は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものである。したがって、行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合、侵害の急迫性の要件については、侵害を予期していたことから、直ちにこれが失われると解すべきではなく……、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には、事案に応じ、行為者と相手方との従前の関係、予期された侵害の内容、侵害の予期の程度、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性、侵害場所にとどまる相当性、対抗行為の準備の状況 (特に、凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等)、実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同、行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意味内容等を考慮し、行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき……など、前記のような刑法 36 条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には、侵害の急迫性の要件を充たさない」としている。よって、丁の行為については、B組組員から襲撃を受けることを予期していたとしても、予期の程度によっては侵害の急迫性を欠くわけではなく、正当防衛又は過剰防衛が成立し得る。したがって、本記述は、丁が果物ナイフで乙の腹部を突き刺した行為については、B組組員から襲撃を受けることを予期し、凶器ともいえるナイフを準備している以上、その予期の程度にかかわらず、侵害の急迫性を欠くとしている点で、誤っている。

オ 正しい

最決平 29.3.27 (百選Ⅱ123 事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「被告人は、前記道路交通法違反及び自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら、同人との間で、A車が盗まれたことにするという、Aを前記各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上、参考人として警察官に対して前記口裏合わせに基づいた虚偽の供述をしたものである。このような被告人の行為は、刑法 103 条にいう『罪を犯した者』をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって、同条にいう『隠避させた』に当たる」としている。その理由として、同判例の小貫芳信裁判官補足意見は、参考人の虚偽供述が犯人の身柄拘束を免れさせる性質の行為に該当するには、客観的に刑事司法作用を誤らせる危険性を有すること、すなわち、当該虚偽供述が犯人の身柄拘束の継続に疑義を生じさせる性質のものであることを要するところ、被告人の虚偽供述内容はAの身柄拘束を免れさせることに直接関わること、また、参考人の供述は、関係者の供述や客観的証拠と整合性があるかどうかを確認して信用性判断がされるものであるが、口裏合わせはその有力な確認方法の一つをあらかじめ奪って、信用性チェックを困難にし、場合によっては虚偽供述の真実らしさを増幅させ、捜査の方向を誤らせる可能性もあり、客観的に刑事司法作用を誤らせる危険性を有するということを挙げている。本記述では、B組事務所の玄関ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所にいたという丁の虚

1156■第7編 総合問題

偽供述内容は、甲がB組事務所の玄関ドアを凹損することが不可能であり、甲が凹損した犯人ではないことを供述内容とするものであるから、甲の身柄拘束を免れさせることに直接関わる虚偽供述内容である。また、同供述が甲との口裏合わせによってなされていることと合わせると、丁の行為は甲の身柄拘束を免れさせる性質の行為とみることができ、「隠避」に当たる。よって、丁の行為については、犯人隠避罪が成立する。したがって、本記述は正しい。